

1500069-41.2022.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... ser ele conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas, tudo o que, acoplado às demais circunstâncias do caso em exame, evidenciam a finalidade do tráfico ilegal.

Dessa forma, considerando o quadro posto, certa a procedência da ação penal.

Oportuno salientar que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500069-41.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-41.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edilson Rodrigues da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. EDILSON RODRIGUES DA SILVA, qualificado a fls. 16, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da

Lei 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 11h45min, na Rua 46 nº 187, Bairro Mutirão II, nas proximidades da USF Cabo Agnaldo Soares, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, cento e onze porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 45,510 g, bem como teria em depósito, com a mesma finalidade, uma porção de cocaína, com peso líquido de 48,550 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, Rua 46, nº 187, Mutirão II, quando visualizaram EDILSON, pessoa muito conhecida pela prática de crimes como tráfico de drogas e roubo, em atitude suspeita, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Em revista pessoal, os agentes públicos encontraram, mais especificamente nas vestes do denunciado, na linha da cintura, um pequeno pote, no interior do qual havia cento e onze pinos contendo cocaína, bem como, em sua carteira, a quantia de cento e setenta reais.

Diante do que encontraram, os policiais, com autorização da genitora de EDILSON, ingressaram em sua residência, onde localizaram, sobre a geladeira, um invólucro contendo cocaína, bem como, sob o tanque de roupas, um pequeno saco contendo cerca de setecentos pinos vazios, com resquícios, e, no guarda-roupas, outros quinhentos pinos, também vazios, além de um aparelho celular, o qual estava na estante da sala.”.

A denúncia de fls. 119/121 foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 123), sendo o Réu citado (fls. 135), apresentando defesa preliminar em fls. 148/152, rejeitada em fls. 155/156. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 221).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 219/220).

A douta Defesa, por seu turno, arguiu preliminares e no mérito sustentou que o Réu manifestou total arrependimento pelo ato cometido, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, requerendo, então, a absolvição pela ilicitude de provas e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência e, não sendo o caso, a fixação da pena no piso legal, com a redução pela confissão, com imposição de regime semiaberto para cumprimento da pena (fls. 239/249).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A primeira preliminar sustentada em memoriais defensivos se liga ao mérito e ali será tratada.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha referida, inviável o acolhimento, uma vez que a genitora do Réu, que somente ao final da instrução pretendeu a Defesa sua oitiva como testemunha referida, se mostra, com a devida vênia, impertinente e protelatória, uma vez que, de início, o artigo 209 do Código de Processo Penal faculta ao magistrado em proceder a oitiva de testemunhas indicadas pelas partes quando lhe “parecer conveniente”. Ocorre que, conforme decidido em fls. 219/220, não surgiu fato novo para que, somente findo o interrogatório judicial, pleiteasse a Defesa que fosse colhido o depoimento da mãe do Acusado, porque sua presença na cena dos fatos era de conhecimento do Réu desde o início e a Defesa disso tinha ciência – ou deveria ter – já que logo dos termos de depoimentos dos policiais, em fls. 02 e 03 destes autos, fizeram menção expressa de que “adentraram em sua residência, local dos fatos, com autorização da genitora de Edilson”. Desse modo, se a Defesa não arrolou a genitora do Réu como testemunha em momento apropriado é porque não tinha interesse em sua oitiva, não podendo

exigir que o magistrado o faça quando não surgiu, repita-se, fato novo que exigisse sua participação nos autos, não podendo a regra do artigo 209, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, ser empregada como sucedâneo de arrolamento intempestivo de testemunhas.

Sendo assim, é o caso de se aplicar o disposto no artigo 400, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal: "As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias". Sobre o tema: "CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Provas postuladas pela defesa que, além de protelatórias, não interfeririam no desfecho da ação penal - Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP - Pleito de nulidade afastado. PRELIMINAR REJEITADA" (TJSP, Ap. 0002663-20.2011.8.26.0459, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Cesar Mecchi Morales, j. 04.01.2014).

No mesmo sentido, "O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regradada do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo (Precedentes do STF e do STJ)" (STJ, HC 138.932/GO, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer, j. 20.10.2009).

De igual forma: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DESCARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO DIANTE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.

I - O deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do Magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente.

II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

III - Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório.

IV - A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório.

V - O argumento de irregularidade da prisão em flagrante do paciente está superado diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

VI - Em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode o habeas corpus ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

VII - Ordem denegada" (STF, HC 98.865/RJ, 1ª T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.05.2010).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/04, no boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, auto de constatação preliminar de fls. 10, pelos laudos de exames químico-toxicológicos a fls. 108/110 e 111/113, no laudo pericial de fls. 174/177, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo sustentou que na data dos fatos estava em sua residência e que, de fato, existia entorpecente no local, mas que tinha sido obrigado a guardar a droga por possuir dívida com um traficante chamado Léo, que exigiu que ele deixasse o entorpecente ali por uma semana. Ressalta que se encontrava em seu quarto quando policiais chegaram, sua genitora abriu o portão e, por isso, o depoente pegou o pote contendo entorpecente e estava no guarda-roupa, tentando sair pelo fundo, mas foi abordado, mostrando a cocaína que estava guardada em casa.

Ademais, disse que estava sob efeito de droga, nada tendo contado aos policiais quando abordado, dizendo que preferia falar somente em Juízo. Declarou também que nem ele e nem sua genitora franquearam o ingresso dos policiais na casa e que reside perto da unidade de saúde.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Sua versão não se sustenta.

O policial militar Rodrigo Reis contou, em Juízo, que estavam em patrulhamento quando avistaram o Réu, conhecido dos meios policiais pelo tráfico, na porta de sua casa, sendo que ele, ao ver a viatura, ficou assustado e tentou entrar na residência, mas foi abordado antes disso, sendo que em revista localizaram consigo a droga que estava em sua cintura, além de dinheiro e celular, de forma que ele foi indagado e confirmou aos policiais que a droga era para a comercialização, pegando ela de um rapaz que conheceu quando cumpria pena, bem como disse que tinha mais no interior de sua casa, com o que ingressaram no local mediante autorização da genitora e encontraram pinos vazios e mais droga. O Réu não aparentava estar sob efeito de entorpecentes e o local é conhecido ponto de venda de drogas. Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento do policial Alan Daniel Moleiro, que ainda declarou que o fato se passou perto da unidade de saúde.

O comportamento do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia tinha em depósito e trazia consigo considerável quantidade de substância entorpecente para fins de traficância. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006. De fato, a forma como a droga estava acondicionada, o tipo, o local da abordagem e a maneira como ela aconteceu, além de ter o Réu confirmado que guardava o entorpecente para terceiro, ao passo que aos policiais relatou que comercializava a droga que pegara de um colega de cela, não devendo se ignorar ser ele conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas, tudo o que, acoplado às demais circunstâncias do caso em exame, evidenciam a finalidade do tráfico ilegal.

Dessa forma, considerando o quadro posto, certa a procedência da ação penal. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, não podendo ser descartados. A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão: “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser

entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A alegação de invasão de domicílio deve ser refutada, considerando que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06 é classificado como permanente, de modo que a consumação se arrasta no tempo e permite a prisão em flagrante a qualquer momento. Sendo assim, não era necessária autorização judicial para ingressar na residência em que se encontrava o Acusado, agindo os agentes policiais dentro da exceção à regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" (destaquei).

Ao contrário do que sustenta a douda Defesa não se constata a existência de irregularidade na atuação dos policiais porque havia justa causa, tendo se baseado os agentes públicos no fato de que o Réu, na porta de sua casa, ao avistar a viatura se assustou e tentou entrar correndo, sendo detido antes disso e consigo localizado parte do entorpecente e, ao ser indagado pelos policiais, confirmou que a droga seria comercializada e que possuía mais no interior de sua residência, motivos mais do que justificados para afastar a alegação de ilegalidade da prisão. Nesse sentido: "inadmissível acenar com 'violação de domicílio', revestida de licitude a conduta dos policiais até porque se cuidava, no caso, de crime permanente, e diante do teor do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, nem era preciso que estivessem eles munidos de mandado judicial de busca, como já se decidiu nesta Corte de Justiça em casos assemelhados (Apel. nº 0000462-78.2014.8.26.0579, rel. Luis Soares de Mello, j. em 27.9.2016; Apel. nº 0001645-68.2014.8.26.0067, rel. Amaro Thomé, j. em 24.11.2016; Apel. nº 0001998-97.2014.8.26.0491, rel. Min. Edison Brandão, j. em 1.11.2016; Apel. nº 0000674-87.2007.8.26.0145, rel. Sérgio Ribas, j. em 31.3.2011). Reiterada aliás essa orientação (HC nº 352.811/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 28.6.2016), inclusive na c. Suprema Corte (RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 5.11.2015)" (TJSP, HC 0023205-68.2017.8.26.0000, 4ª C.D.Crim., Relª Desª Ivana David, j. 31.10.2017).

De igual forma: "recentemente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616, o C. Supremo Tribunal Federal aprovou a tese, em repercussão geral, segundo a qual a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas posteriormente que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Entendeu-se que, segundo o artigo 33 da Lei de Drogas, configura-se delito permanente guardar entorpecentes ou mantê-los em depósito e o artigo 303 do Código de Processo Penal considera como situação de flagrância aquele que estiver cometendo crime permanente" (TJSP, Revisão Criminal 0008744-28.2016.8.26.0000, 5º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 14.09.2017).

De fato, o procedimento adotado pelos policiais, conforme acima mencionado, está de acordo com o entendimento firmado pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Sobre o tema: “a ideia de abuso de autoridade em decorrência da invasão de domicílio, sem ordem judicial, na forma como sugerido pela combativa Defesa, não impede o prosseguimento da ação penal. A conduta imputada ao réu (guardar entorpecente) é crime de natureza permanente, cujo momento consumativo se protraí no tempo, autorizando a qualquer momento a ação policial. Não por outro motivo, recentíssima decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu como legítima a busca e apreensão sem mandado judicial em crime permanente (HC 127457). O relator do caso, ministro Dias Toffoli, lembrou em seu voto que diversos precedentes da Corte apontam no sentido de ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas. Isso porque, no caso de crime permanente, explicou o ministro Celso de Mello ao acompanhar o relator, o momento consumativo do delito está sempre em execução. (<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293229> acesso em 11.06.2015).

Por ora, os elementos indiciários contidos no caderno policial sugerem que os milicianos agiram no estrito cumprimento do dever legal, posto que fundadas razões, em torno da possível prática delitiva, inclusive de ordem objetiva, justificaram o ingresso no imóvel apontado na denúncia, como forma de combate à criminalidade que ocorria.

Daí que, na forma como já advertido pela Suprema Corte, 'do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida. (...) Por estar a certeza fora do alcance, a legislação costuma exigir modelos probatórios bem mais modestos para medidas de investigação. Para busca e apreensão, por exemplo, o Código de Processo Penal exige apenas fundadas razões' (STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 05.11.2015)” (STJ, HC 435465, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.02.2018).

Assim, tem-se a declaração isolada do Réu dada em Juízo que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Uma observação que deve ser feita, contudo, é que apesar de o crime, apesar de ter ocorrido a certa proximidade do equipamento público, não houve demonstração de que o Réu se valia deste fato para praticar o tráfico, com o que não é o de reconhecer a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, lembrando-se que a mens legis almeja reprimir com maior severidade o tráfico em locais com grande circulação de pessoas, facilitando a difusão de entorpecentes. Sobre o tema: “Reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Agente flagrado em via pública durante a madrugada, quando não havia movimentação de estudantes no local” (TJSP, Ap. 0091596-66.2010.8.26.0050, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Salles Abreu, j. 28.02.2012).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta maus antecedentes, consistente em condenações criminais sem efeitos para reincidência (fls. 39/40, autos nº 0000206-70.2015.8.26.0557, fls. 40, autos nº 0001699-95.2011.8.26.0210, fls. 40/41, autos nº 0003030-49.2010.8.26.0210, fls. 42, autos nº 0004438-51.2005.8.26.0210, fls. 43/44, autos nº 0006149-57.2006.8.26.0210) e que podem ser utilizadas sem risco de incorrer em bis in idem com a reincidência porque são processos distintos, o que demonstra personalidade voltada para a prática de condutas antissociais e exige resposta estatal mais

vigorosa. Some-se a isso a considerável quantidade de cocaína apreendida com o Réu, indicando que iria abastecer o comércio clandestino por um bom período, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, promovo o aumento da pena-base em 1/4 (um quarto) e a fixo em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/5 (um quinto) em razão da reincidência (cf. fls. 44, autos nº 1501547-89.2019.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Quanto a isso, observo que artigo 28 da Lei 11.343/06, fundamento da condenação anterior do Réu, permite seu emprego para reconhecer a reincidência, porque a posse de substância entorpecente continua sendo crime, não tendo ocorrido descriminalização desta conduta, que não se confunde com a mera despenalização. Sobre o tema: "ao concluir pela reincidência por condenação anterior definitiva pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para manter a não incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a autoridade tida por coatora decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 'Agravos regimentais no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse de droga para consumo pessoal (art. 28 de Lei nº 11.343/06): natureza jurídica de crime. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 3. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso. 4. Agravo regimental não provido' (AI 741.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2011, grifos nossos)" (STF, HC 127.333/SP, Relª Minª Cármen Lúcia, j. 27.03.2015).

Ademais, não se pode falar em confissão porque o Réu aplicou evasiva para justificar a localização do entorpecente em sua residência, dizendo-se coagido a tanto por dívida com traficantes, o que, fosse acolhido – e não o é por não haver demonstração de sua veracidade – resultaria em sua absolvição.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele, portador de péssimos antecedentes e reincidente, conhecido pela traficância, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, ainda que sustente possuir ocupação remunerada que, pela própria natureza, não impedia de exercer a traficância, tanto que preso em flagrante em horário ao qual deveria estar trabalhando.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta

objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal

de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado telefone celular que era empregado no tráfico, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda desse bem apreendido com o Réu, que deverá ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu EDILSON RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis. No mais, decreto a perda do telefone celular apreendido com ele, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhem-se o bem apreendido, acima mencionado, em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez, por seus péssimos antecedentes e ainda por sua reincidência, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, mantendo, então, sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois nada justifica que, preso em flagrante, fosse colocado em liberdade depois de condenado.

São devidas custas na forma da lei, pedido de fls. 249 que ora defiro uma vez presentes os requisitos legais.

P.R.I.C.

Guaíra, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA